

1500033-46.2021.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... lícita, na medida em que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente e o fato do réu ter entrado em luta corporal com os policiais e ter fugido evidencia a fundada suspeita ensejadora da busca na residência.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal Bandeirante:

Apelação - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Insurgência quanto à validade das buscas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500033-46.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500033-46.2021.8.26.0626

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2003058/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 15504876 - DEL.POL.UBATUBA, 100/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2003058 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO BRAGA DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de RICARDO BRAGA DE CARVALHO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Conforme se extrai da denúncia, na data e local dos fatos, mantinha em depósito para fins de tráfico 47 pinos de cocaína (41,6 g), 27 pedras de crack (10,25g) e 02 porções de maconha (8,26g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 18 e auto de constatação preliminar de fls. 19. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Ricardo Braga de Carvalho possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da sua residência, 25 munições intactas, calibre .22, de uso permitido, fazendo-o sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 18 e laudo pericial a ser oportunamente juntado. Segundo o apurado, Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina quando decidiram abordar o réu, que, alterado, não obedeceu ao comando dos policiais entrando em luta corporal e se evadindo até a residência sem número situada na Rua Canaã próxima ao nº 210, onde ele foi detido após novo embate corporal. Próximo à entrada da referida residência, em cima de um armário, os agentes lograram êxito em localizar uma sacola contendo 47 (quarenta e sete) pinos de "cocaína", 27 (vinte e sete) pedras de "crack", 02 porções de "maconha" e um pacote de plástico contendo 25 (vinte e cinco) munições intactas de calibre 22. Indagado, Ricardo assumiu informalmente a propriedade de todo material apreendido e declarou que as munições seriam para vingar a morte de tal "Elriel" e que a arma estaria escondida em outro local, negando-se a indicar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Auto de exibição e apreensão (fls. 18). Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 19). Certidão de distribuição criminal (fls. 39/40). Folha de Antecedentes (fls. 41/42). Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 58/61). Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (fls. 91/93). Exame de arma de fogo (fls. 94/96). Defesa Preliminar (fls. 117/118). Recebimento da denúncia (fls. 126/127). Termo de audiência com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu (fls. 160/161). Alegações Finais, na forma de memoriais, do Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 153/159). Alegações Finais, na forma de memoriais, da Defesa requerendo que seja o réu absolvido, (fls. 162/166). É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

Insta, a priori, reproduzir a prova oral coletada em juízo.

O policial militar Ronaldo narrou que estavam em patrulhamento quando entraram próximo à Rua Canaã e determinaram que o réu parasse para ser abordado. Nesse momento, o réu ficou agressivo e foi para cima da guarnição, entrou em luta corporal e fugiu para o final da Rua Canaã. Chamaram outra viatura e foram até o final da rua. O réu estava em um terreno que havia diversas casas. Chamaram o réu, momento em que ele entrou em luta corporal com os policiais, mas foi contido e machucou a cabeça. Entraram na casa do réu, juntamente com ele, para pegar seu RG e acabaram encontrando no hack uma sacola com mais de 20 munições calibre .22. Também encontraram um saco plástico com crack, cocaína e maconha. O réu confessou que as munições e as drogas eram dele. O réu autorizou a entrada dos policiais em sua casa. O réu disse que as munições seriam para matar uma pessoa que matou um amigo dele. O réu também ameaçou matar os policiais. O réu é conhecido nos meios policiais e já foi abordado várias vezes naquele local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

O policial militar Eduardo narrou que estavam em patrulhamento quando viram o réu que tentou resistir à abordagem. O réu conseguiu se evadir em direção à sua casa. Chamaram apoio e foram até a casa do réu. Chamaram o réu que saiu de sua casa e houve resistência em relação à equipe de policiais, mas conseguiram detê-lo. O réu caiu e teve um corte na cabeça. Seu parceiro entrou na casa do réu para pegar o RG dele e encontrou as munições e drogas. O réu confessou que as munições e as drogas eram dele. O réu disse que as munições eram para vingar a morte de um amigo. Não tinha ninguém na rua. O réu autorizou a entrada em sua casa para os policiais pegarem seu documento.

A informante Maria Braga, mãe do acusado, disse que o réu trabalhava em um lava rápido na época em que foi preso. O réu tem dois filhos e sempre trabalhou.

A testemunha Juliana narrou que estava no local dos fatos quando o réu foi preso. Viu que o réu estava ensanguentado e os policiais entraram na residência dele sem permissão. Os policiais não disseram o que ocorreu. Quando seu pai foi perguntar o que ocorreu aos policiais, eles disseram que encontraram arma, mas só mostraram umas "balas" de revólver. Os policiais não mostraram mais nada. Os policiais não a chamaram para entrar na casa. Tinha outras pessoas na rua no momento da prisão. Viu os policiais batendo no réu. O réu trabalhava em um lava rápido. Respondendo às

perguntas do Ministério Público, Juliana afirmou que estava dormindo no momento dos fatos. Disse que na verdade as pessoas da rua que falaram que os policiais entraram na residência do réu sem permissão.

A testemunha Everaldo disse que no momento dos fatos estava dormindo. Acordou com sua filha gritando. Subiu para ver o que estava acontecendo e viu uma policial batendo no réu. Disse para ela parar de bater e levá-lo preso. Quando chegou, os policiais já estavam dentro da casa do réu. Os policiais mostraram para ele algumas munições encontradas, mas não viu drogas. O réu trabalha em um lava rápido. Não sabe se o réu usa ou vende drogas.

Interrogado, o réu narrou que no dia dos fatos foi até um bar para comprar algumas coisas para fazer comida. Viu os policiais abordando uma menina na esquina. Nesse momento, os policiais Eduardo e Ronaldo o cercaram. Esses policiais sabem que ele trabalha no lava rápido. Os policiais já o abordaram outras vezes. Quando os policiais tentaram abordá-lo ele disse que tinha acabado de sair do trabalho e estava indo comprar algo para comer. Nesse momento os policiais o agrediram, ele caiu no chão e saiu correndo. Chegou em casa e gritou pedindo ajuda para Juliana. Nesse momento, os policiais chegaram, invadiram sua casa e o espancaram, inclusive com coronhadas. Ele tinha 25 munições em casa, mas elas não prestavam. Falou com o Delegado que não foram apreendidas drogas com ele. Não tem arma. Ele disse aos policiais que iria processá-los porque ele era trabalhador. Em momento algum autorizou a entrada dos policiais em sua casa.

Passo à análise dos crimes imputados ao réu.

Primeiramente, saliento que a invasão da residência do réu sem mandado de busca e apreensão está justificada, pois, apesar da negativa do réu, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o réu franqueou a entrada deles no local.

Assim, a alegação de que os policiais militares entraram na residência do acusado sem sua autorização se apresenta, portanto, como mera conjectura, desprovida de lastro probatório.

Isso porque seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública.

Também não há comprovação nos autos de que os policiais teriam mentido para incriminarem falsamente o réu.

Mesmo que não fossem autorizados pelo réu, a entrada da polícia na residência do acusado se mostra lícita, na medida em que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente e o fato do réu ter entrado em luta corporal com os policiais e ter fugido evidencia a fundada suspeita ensejadora da busca na residência.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal Bandeirante:

Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Insurgência quanto à validade das buscas domiciliares, com a consequente absolvição do réu – Não acolhimento – Diligências lícitas – Entrada dos policiais na residência franqueada pela genitora do acusado – Traficância amplamente demonstrada pelas provas colhidas – Condenação correta – Dosimetria – Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado – Descabimento – Circunstâncias que demonstram que o réu fazia da mercancia ilícita seu sustento e não se tratava de traficante ocasional – Reprimenda inalterada – Regime fechado correto – Substituição penal impossível – Apelo desprovido. (TJ-SP - APR: 15000024720208260598 SP 1500002-47.2020.8.26.0598, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 09/02/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2021 - grifei)

1) Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

A materialidade consubstancia-se no Auto de exibição e apreensão (fls. 18), Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 19) e no Exame químico-toxicológico (fls. 91/93).

A autoria ficou comprovada mediante a prova oral produzida em juízo, principalmente pelos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu Ricardo, em juízo, negou que havia drogas em sua casa. Disse que os policiais invadiram sua residência, mas não encontraram drogas. Inclusive falou com o

delegado de polícia que as drogas apresentadas não foram encontradas em sua casa, dando a entender que os policiais teriam “forjado” aquelas drogas apresentadas. Sem embargo, a versão exculpatória do réu não convence e ficou isolada quando contrastada com o acervo probatório.

Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que, após terem a entrada na residência do réu franqueada por ele, encontraram um saco plástico com 47 pinos de cocaína (41,6 g), 27 pedras de crack (10,25g) e 02 porções de maconha (8,26g). Impende ressaltar a inexistência de qualquer óbice em relação ao depoimento prestado por policiais, uma vez que a eles inexiste qualquer impedimento para testemunhar, sendo certo que seus depoimentos são merecedores de crédito como os de qualquer outra testemunha, bem como sujeitos a penalidades se falseado a verdade, que, todavia, não ocorre no presente feito. Nesse diapasão, farta é a

Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Assim, pelo cenário observado e pela quantidade de droga apreendida e sua forma de acondicionamento (pequenas porções pronta para comercialização), quais sejam, 47 pinos de cocaína (41,6 g), 27 pedras de crack (10,25g) e 02 porções de maconha (8,26g), e pelo fato de serem encontradas 25 munições na residência do réu, é certo que as drogas se destinavam à traficância, restando o ato do réu enquadrado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, pois mantinha em depósito e guardava drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar com o objetivo de traficá-las. Enfim, do cotejo dos elementos de prova amealhados, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos seguros e harmônicos relatos dos agentes públicos confirmam a autoria do réu no crime de tráfico de drogas, sendo mesmo de rigor o desfecho condenatório.

Formada a culpa, passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais a serem consideradas. Assim, fixo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifica-se a aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas indicando sua participação em organização criminosa. Além disso, não há elementos seguros demonstrando o tráfico habitual. Contudo, o réu não faz jus à redução máxima de 2/3, mas sim da metade. Valora-se em desfavor dele a qualidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack) cujo poder vulnerante à saúde é bem superior a de outros entorpecentes, além da considerável quantidade de drogas apreendidas. Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados em seu patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo.

Neste sentido, decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Não há ilegalidade na aplicação do redutor de ½ (metade, de acordo com o previsto nos art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CP, dadas as circunstâncias do caso concreto, bem como a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas com o paciente (...). (HC 219.971, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 17/04/2012).

2) Do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03:

A materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido foi comprovada pelo Auto de exibição e apreensão (fls. 18) e Laudo Pericial da arma de fogo (fls. 94/96).

Já a autoria foi comprovada pelo depoimento dos policiais em juízo e pela confissão do réu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que, após terem a entrada na residência do réu franqueada por ele, encontraram dentro de uma sacola, sobre o hack da sala, 25 munições intactas, calibre .22.

Além disso, o réu confessou, sob o crivo do contraditório, que realmente tinha 25 munições em sua casa.

Ademais, as munições passaram por perícias (fls. 94/96) que concluiu o seguinte: Foram apresentadas para exame, acondicionadas em invólucro plástico transparente, a(s) seguinte(s) peça(s) sob lacre 00002317:

- 25 (vinte e cinco) munições de calibre .22", íntegras, marca CBC, ponta ogival desencamisada.

(...)

Quando dos ensaios de disparo com a munição, após minuciosa análise física e visual de todas, foram selecionadas, aleatoriamente 06 (seis) munições de calibre de forma aleatória. Todas elas funcionaram a contento, constatando-se assim a eficácia dos mesmos quanto à potencialidade lesiva da munição. Assim, estes cartuchos foram utilizados nos exames, deixando de acompanhar o presente laudo. Era o que havia a relatar.

Isto posto, configurando os requisitos para a prolação de édito condenatório pela prática do delito disposto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, a perícia comprovou as munições poderiam ter sido utilizadas de maneira eficaz e o réu não tinha o respectivo registro para possuí-las.

Nesse sentido, é a análise a contrario sensu do definido pelo doutrinador Fernando Capez:

"Conforme dissemos, se a arma for totalmente inapta a efetuar disparos será considerada obsoleta, não havendo que falar em registro, e, por conseguinte, em violação à norma do art. 12 (ou, conforme o caso, do 14) da Lei. (...) Arma totalmente inapta a disparar não é arma, caracterizando-se a hipótese de crime impossível pena ineficácia absoluta do meio. (...) Deve-se ainda salientar que, sendo a arma eventualmente ineficaz (às vezes disparar, às vezes não), existirá crime, não havendo que se falar em crime impossível. (...)". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial, volume 4 / Fernando Capez. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Portanto, a condenação do réu pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03 é medida de justiça.

Formada a culpa passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Portanto, fixo a pena base 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase está presente a atenuante da confissão. Contudo deixo de atenuar a pena em patamar aquém do mínimo legal por expressa vedação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, pelo que a torna definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em seu piso mínimo legal.

3) Do regime inicial para o cumprimento de pena:

Havendo concurso material de crimes, pois o réu praticou, mediante mais de uma ação ou omissão, o crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido, as penas serão aplicadas cumulativamente (art. 69, do CP), pelo que somam 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta)

dias-multa.

Apesar da quantidade de pena aplicada, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente as drogas provocam, notadamente a cocaína e o crack.

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Apoio-me no entendimento no sentido de que o artigo 44, da Lei de Drogas, não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição está sustentada no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo em casos de tráfico de drogas privilegiado, a hediondez do delito não está afastada.

Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do SURSIS, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitiva, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Nesse sentido, magistério do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade, nos casos apontados no art. 44, caput, desta Lei [Lei nº 11.343/2006], por restritiva de direitos. Nenhuma inconstitucionalidade existe, pois não fere a individualização da pena. Cuida-se de política criminal do Estado, buscando dar tratamento mais rigoroso ao traficante, mas sem padronização de penas. Porém, há uma ressalva: é norma penal prejudicial ao réu, razão pela qual somente pode ser aplicável aos fatos cometidos após a entrada em vigor da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery:

“inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente pretensão punitiva para CONDENAR o réu RICARDO BRAGA DE CARVALHO pelos seguintes crimes:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em seu piso mínimo legal. O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado pelos motivos expostos na aplicação da pena.

B) Art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em seu piso mínimo legal. O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado pelos motivos expostos na aplicação da pena.

Oficie-se a autoridade policial para a incineração dos entorpecentes apreendidos. Encaminhem-se as munições para o comando do Exército Brasileiro para a destinação legal.

Custas ex legis, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que permanecem presentes os fundamentos constantes da r. decisão que a decretou. Acrescente-se àqueles argumentos a gravidade concreta da ação praticada, expostas linhas acima, mais

precisamente na motivação da escolha do regime inicial fechado.
Arquivem-se os autos oportunamente.
Publique-se e intime-se.

Ubatuba, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA